

1504059-14.2020.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504059-14.2020.8.26.0597

Controle: 2020/002241

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência 5032392/2020 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ DIEGO BATISTA BARBOSA FERREIRA

Réu Preso

Aos 19 dias do mês de janeiro de 2022, às 15:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS: o Promotor de Justiça, Dr. DANIEL TOSTA DE FREITAS; o réu Luiz Diego Batista Barbosa Ferreira e seu Defensor nomeado, Dr. WÁGNER JOSÉ CLEMENTI (OAB/SP 122851). AUSENTES: as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Civis Municipais Bruno Carvalho de Souza e Wendel Renan Barbosa da Silva que já foram ouvidos as fls. 156 e 157. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz interrogou o réu Luiz Diego Batista Barbosa Ferreira, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dr. Defensor, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos.

LUIZ DIEGO BARBOZA FERREIRA, vulgo "Dodô" qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 01h53min, na Rua Delfino Eleotério de Almeida nº 1020, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo 2,85g (dois gramas e oitenta e cinco decigramas) de cocaína, acondicionada em 17 (dezessete) microtubos plásticos do tipo "eppendorf", e 10,70g (dez gramas e setenta decigramas) de maconha, acondicionada em 12 (doze) invólucros plásticos transparentes, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, Guardas Civis Municipais estavam em patrulhamento quando avistaram o réu no local mencionado; ao perceber a aproximação da viatura, o réu arremessou algo embaixo de um trailer de lanches e tentou evadir-se. Em seguida, os policiais realizaram abordagem e encontraram dois pinos de cocaína e doze trouxinhas de maconha, além da quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em posse do réu; além disso, o objeto arremessado para baixo do trailer tratava-se de outros quinze pinos de cocaína.

A denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2021 (fls. 99/100). O réu foi citado por edital (fls. 125).

Em 03 de agosto de 2021, o processo foi suspenso, bem como seu curso prescricional, sendo decretada a produção antecipada de provas (fls. 133).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 138/139).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas de que a droga se destinaria à comercialização, posto que o réu é apenas usuário, de forma que deverá ainda desclassificada a imputação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de penas restritivas de direito.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 19/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13), pelas imagens fotográficas (fls. 15 e 16) e laudos químico-toxicológicos (fls. 79/81 e 82/83), conclusivos por se tratar de cocaína e maconha, respectivamente, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os Guardas Municipais Civis Wendel e Bruno disseram, na fase policial, que estavam ambos juntos em um patrulhamento de rotina quando avistaram o réu, o qual estava parado, vindo a andar cerca de cinco metros e, logo em seguida, arremessou algo, que caiu embaixo de um trailer de lanches. Em seguida, o réu foi abordado e, com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína, doze "trouxinhas" de maconha e R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie. Afirmaram, ainda, que sob o trailer para o qual foi arremessado o objeto foram encontrados mais quinze pinos de cocaína, totalizando dezessete desta substância (fls. 06/07).

O Guarda Civil Municipal Wendel, em Juízo, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público, disse que estavam em patrulhamento, quando viram Diego, o qual estava parado e, ao ver a viatura, jogou algo ao solo, que caiu embaixo de um trailer. Diante disso, resolveram abordá-lo, oportunidade na qual foi encontrado maconha, cocaína e dinheiro em posse do acusado. Após, verificaram que o objeto arremessado pelo acusado se tratava de mais entorpecentes (maconha e cocaína). O réu confessou que estava vendendo drogas (v. mídia).

O Guarda Civil Municipal Bruno, em Juízo, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público, disse que estavam em patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram o acusado em comportamento suspeito, tendo em vista que, ao ver a viatura policial, arremessou algo embaixo de um trailer e, após, saiu andando. Após, abordaram-no e, com ele, foi encontrada maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Na sacola arremessada pelo acusado, foi encontrada maconha e cocaína. Disse que o acusado era conhecido nos meios policiais pelo delito de furto. Ainda, afirmou que já havia abordado o acusado anteriormente, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado pela Defesa, disse que viram exatamente o momento em que o acusado arremessou a sacola embaixo do trailer. Relatou que o réu negou ser andarilho e disse que passava uns dias na casa de uma tia dele, que mora no condomínio Aragão. Afirmou que os fatos aconteceram por volta de 01h00, sendo que o carrinho de lanches para onde a sacola foi arremessada já estava fechado (v. mídia).

O réu, interrogado na fase policial, disse que é usuário de entorpecentes e alegou que estava apenas consumindo as drogas quando foi abordado. Alegou não praticar a venda de drogas e disse que o valor encontrado era para comprar entorpecentes. Explicou que não possui familiares na cidade de Sertãozinho, apenas em Barrinha. Disse ainda que parou de frequentar escola e alegou ser menor de idade, com 16 (dezesesseis) anos. Disse ainda que não sabe ler e nem escrever e que esta residindo nas ruas, pois brigou com a mãe. (fls. 09).

Em Juízo, negou a acusação. Disse ser pedinte e que, após utilizar o serviço de um mototáxi, foi ao local dos fatos para comprar a droga. Tinha acabado de comprar a droga quando foi detido. Estava na posse de R\$ 2,00, além de 4 pinos de cocaína e 5 porções de maconha quando foi detido, droga esta que se destinaria ao uso próprio. Era morador de rua na época dos fatos (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida, e que se destinaria a consumo de terceiros.

Os guardas municipais narraram de maneira uníssona que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu. Nisto, Luiz Diego jogou para debaixo de um trailer um objeto e tentou fugir.

Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse 02 pinos de cocaína e 12 trouxinhas de maconha, além da quantia de R\$ 56,00. Ressalto ainda que o objeto arremessado para debaixo do trailer tratava-se de mais 15 pinos de cocaína, substâncias essas todas apreciadas pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13), pelas imagens fotográficas (fls. 15 e 16) e laudos químico-toxicológicos (fls. 79/81 e 82/83).

A versão do réu, de que estava apenas consumindo as substâncias além da negativa sobre estar traficando, não convencem.

O fato de o réu ser usuário ou dependente no uso de droga também não impede que também estivesse traficando na ocasião, mesmo porque é de se observar que durante a fase policial, o réu mentiu sobre sua idade, como se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 19/20, dizendo ter 16 anos quando na verdade possuía 18 anos de idade, evidenciando meio para esquivar-se de penalidade imposta ao tráfico de drogas.

Ademais, considerando que a significativa quantidade de droga encontrada é superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, bem como a forma em que estava acondicionada, em porções individuais próprias para comercialização, mantendo parte da droga em sua posse e tentando livrar-se das substâncias e evadir-se com aproximação policial, em atitude típica dos traficantes que atuam no local, conclui-se que efetivamente praticava o tráfico na ocasião.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos guardas ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados ou obter vantagem indevida.

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Reputo que a acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

“O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada.” (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminoso, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariiedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariiedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado,

prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela destruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUIZ DIEGO BARBOZA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06. Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade, expedindo-se alvará de soltura.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e seu Dr. Defensor foi dito que RENUNCIAM ao direito de recurso. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: “Diante da renúncia da Defesa ao direito de recorrer, bem como da concordância do Ministério Público com a decisão, o que acarreta a preclusão lógica, homologo a renúncia, certifique-se o trânsito em julgado para as partes. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado Dr. Wágner José Clementi em 100% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais.” Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.